

DERECHO SOCIETARIO

INTRODUCCIÓN - LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN

§ 1. IMPORTANCIA DE LA REFORMA EFECTUADA POR LA LEY 26.994 AL RÉGIMEN LEGAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. ORDEN DE PRELACIÓN RESPECTO DE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS SOBRE PERSONAS JURÍDICAS

Debe destacarse, en primer lugar, la importancia de la inclusión del título II del Código Civil y Comercial de la Nación (Cód. Civ. y Com.), aprobado por la ley 26.994 del 1 de octubre de 2014, con vigencia a partir del 1 de agosto de 2015, que introdujo trascendentes modificaciones en torno al régimen de las personas jurídicas en general, a través de una serie de normas, en su mayor parte de carácter imperativo.

Las normas de los arts. 141 a 167 del Código Civil y Comercial son aplicables a todas las personas jurídicas reguladas legalmente, salvo que las leyes especiales (ley general de sociedades, sociedades por acciones simplificadas, mutuales, cooperativas, asociaciones civiles, fundaciones etc.), contemplen una solución distinta frente al mismo caso, a través de sendas normas imperativas, pues si la colisión normativa se produce entre una norma de esta naturaleza contenida en el nuevo régimen de las personas jurídicas y una norma supletoria o estatutaria no imperativa contenida en la ley especial, predomina la primera de ellas, a tenor de lo dispuesto por el art. 150 del Cód. Civ. y Com. La trascendencia de esta solución salta a la vista y basta afirmar, a título de ejemplo, la aplicación a todas las personas jurídicas de las normas de los arts. 158 y 161 del referido Código, que prevén expresamente tres soluciones: la posibilidad de celebrar reuniones de los órganos del órgano de gobierno por vía electrónica, el derecho de autoconvocarse por el mismo órgano y la adopción de determinadas medidas para superar la imposibilidad fáctica de tomar decisiones en el órgano de administración, cuestiones estas dos últimas que, conforme lo enseña la experiencia, se presentan todos los días, en especial cuando las sociedades transitan un conflicto societario interno.

De manera que, sobre la base de lo dispuesto por el art. 150 del Cód. Civ. y Com. no existe el menor óbice para superar el silencio de la ley 19.550 en torno a dichas cuestiones, aplicando al respecto lo dispuesto por los arts. 158 y 161 del Cód. Civ. y Com.

§ 2. LA DEFINICIÓN DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL ACTUAL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN. SU CLASIFICACIÓN. PERSONALIDAD JURÍDICA.

INOPONIBILIDAD. COMIENZO DE SU EXISTENCIA. CLASIFICACIÓN. PERSONAS

Definición de las personas jurídicas

El art. 141 del Cód. Civ. y Com. prescribe expresamente que "Son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y fines de su creación".

Reconoce expresamente el carácter de sujeto derecho de las entidades previstas en los arts. 146 y 148, y cuyo alcance ha sido definido por lo dispuesto por el art. 143, en cuanto dispone que la persona jurídica tiene una personalidad distinta de la de sus miembros.

Lo primero que debe destacarse en torno a la definición contenida en el art. 141 del Cód. Civ. y Com. es que vuelve a reiterarse la limitación de la capacidad de las personas jurídicas, en tanto estas solo pueden adquirir derechos y contraer obligaciones, para el cumplimiento de su objeto y fines de su creación.

Se trata del clásico principio de especialidad o del *ultra vires*, que limita la actuación de los sujetos colectivos a la celebración de todos los actos jurídicos que considere necesarios, pero siempre que tengan relación con el cumplimiento del objeto o el fin de su creación, siendo de toda obviedad sostener que la gente se junta, al constituir una persona jurídica, en torno a un objetivo, que es de lucro, en el caso de sociedades o de procura del bien común, tratándose de asociaciones civiles o fundaciones.

Debe recordarse asimismo que la aplicación del principio de la especialidad, como se denomina a esta limitación a la capacidad de las personas jurídicas cuando se habla fundamentalmente de las asociaciones civiles, fundaciones o mutuales, o la *doctrina del ultra vires*, cuando se trata de analizar la capacidad de las sociedades comerciales, no es estricto, pues la capacidad acordada con relación a los fines de la persona jurídica se extiende a todas las relaciones jurídicas que concurran directa o indirectamente al cumplimiento del objeto o a los fines de su creación, y es por ello que el art. 58 de la ley 19.550 solo torna inoponibles los actos celebrados por la sociedad comercial que resulten "notoriamente ajenos al objeto social".

Personalidad jurídica. Mi adhesión a la teoría de la ficción

El carácter de sujeto de derecho que gozan las personas jurídicas, y a diferencia de lo que acontece con las personas humanas, no proviene del derecho natural, sino que es una solución práctica que el legislador aporta para unificar en un solo sujeto o en un solo patrimonio los efectos de la actuación de un grupo de personas que se han unido a los fines de llevar a cabo una actividad en común.

Se trata —en definitiva— de una ficción, tesis a la cual adhirió en su momento Vélez Sarsfield, siguiendo las enseñanzas de Savigny, Laurent, Aubry y Rau, entre otros, y que por mi parte y a pesar de su antigüedad, considero totalmente

vigente, pues, como lo explica Borda, cuando la ley considera y trata al hombre como persona, ella no le confiere personalidad, sino que solo reconoce y confirma una personalidad preexistente, partiendo de la base de que el único sujeto natural de derechos y obligaciones es el hombre. Ello no sucede con las personas jurídicas, pues cuando el derecho otorga la capacidad jurídica a una persona que en realidad no tiene ni pensamiento ni voluntad, no es sino por una ficción que lo hace y esa ficción consiste en admitir que ese ente piensa y quiere, aunque sea materialmente incapaz de hacerlo. Por esa razón de conveniencia o de interés económico o social, el derecho las considera como si fueren personas, pero que por derecho natural no lo son.

Estas conclusiones no implican negar la existencia de las personas jurídicas como sujetos de derechos diferentes de las personas que la integran, pero ello debe explicarse —se reitera— por los beneficios que a la comunidad, al bien común, al tráfico mercantil o a los terceros implica unificar en un solo patrimonio las relaciones jurídicas llevadas a cabo por un grupo de personas aglutinadas en torno a un mismo fin.

En los fundamentos expuestos por los autores del Código Civil y Comercial del año 2014, sus autores se han pronunciado en favor de las doctrinas que conciben a la personalidad jurídica como una concesión estatal, al enunciar que "la personalidad jurídica es conferida por el legislador como un recurso técnico según variables circunstancias de conveniencia o necesidad que inspiran la política legislativa".

Inoponibilidad de la personalidad jurídica

En esta línea de pensamiento y con idéntico objetivo que el art. 54, tercer párrafo, de la ley 19.550, el art. 144 del Cód. Civ. y Com. consagró para todas las personas jurídicas la doctrina de la inoponibilidad de la personalidad jurídica, disponiendo expresamente que "La actuación que esté destinada a la consecución de fines ajenos a la persona jurídica, constituya un recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe, o para frustrar derechos de cualquier persona, se imputa a quienes a título de socios, asociados, miembros o controlantes, directos o indirectos, la hicieron posible quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados. Lo dispuesto se aplica sin afectar los derechos de los terceros de buena fe y sin perjuicio de las responsabilidades personales de que puedan ser pasibles los participantes en los hechos por los perjuicios causados".

El art. 143 del Cód. Civ. y Com. recoge también estas realidades, que de ninguna manera podía desconocer, y si bien el primer párrafo de dicha norma prescribe que "La persona jurídica tiene una personalidad distinta a la de sus miembros", para afirmar, de seguido, que "Los miembros no responden por las obligaciones de la persona jurídica", lo cual es el efecto más concreto e importante del reconocimiento del carácter de sujeto de derecho de las personas ideales, lo cierto es que, de inmediato, establece que "excepto en los supuestos que expresamente se prevén en este Título y lo que disponga la ley especial", con lo cual abre el camino para la consagración, en el art. 144 del Cód. Civ. y Com. de la doctrina de la inoponibilidad de la personalidad jurídica para todas

las personas de existencia ideal.

Es de toda evidencia sostener que, cuando el art. 143 del Cód. Civ. y Com. se refiere en su último párrafo a "la ley especial", lo hace teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 54, tercer párrafo, de la ley 19.550 que, como fuente directa del art. 144 del Cód. Civ. y Com., se encuentra inserta en la ley 19.550, aunque, como lo enseña la jurisprudencia, su ámbito de aplicación trascendió a las sociedades comerciales y fue aplicada a las personas jurídicas de carácter privado, pues consagraba una solución lo suficientemente justa para ser impuesta a todos quienes abusaron del otorgamiento de la personalidad jurídica a los entes ideales, cualquiera que fuere la naturaleza de estos (asociaciones civiles, fundaciones, mutuales, cooperativas etc.). Sin embargo, la existencia de diversas y hasta contradictorias interpretaciones sobre el alcance de algunas de las soluciones consagradas en aquella norma, que, data del año 1982, obligaron a los redactores del Código Civil y Comercial de la Nación a ser muy cuidadosos en los términos de la redacción del art. 144, que —a nuestro juicio— ha mejorado con creces el texto del art. 54, tercer párrafo, de la ley 19.550 y contribuido a una interpretación más acertada en torno a las intenciones del legislador.

El art. 144 del Cód. Civ. y Com. ha sustituido la fórmula "fines extrasocietarios" del art. 54 de la ley 19.550 por "fines ajenos a la persona jurídica", modificación que responde al hecho de que aquella norma trasciende a las sociedades comerciales y resulta de aplicación a todas las personas jurídicas, siendo importante destacar que la finalidad en ambas normas ha sido exactamente la misma, esto es, evitar la proliferaciones de entidades ficticias e imputar la actuación o la titularidad del patrimonio de estas a quienes son sus verdaderos y reales propietarios, sin perjuicio de la responsabilidad de estos, cuando así correspondiera.

Se recuerda finalmente que, en principio, la solución prevista en el art. 144 del Cód. Civ. y Com. no implica necesariamente la nulidad del ente, sino simplemente su inoponibilidad o su actuación desviada, imputando las consecuencias y efectos de la ilegítima o extrasocietaria operación a sus responsables, generalmente beneficiarios de esa manera de proceder.

El comienzo de la existencia de las personas jurídicas

El art. 142 del Código Civil y Comercial de la Nación dispone en el art. 142 del Cód. Civ. y Com., bajo el título de "Comienzo de la existencia" que "La existencia de la persona jurídica privada comienza desde su constitución. No necesita autorización legal para funcionar, excepto disposición legal en contrario. En los casos en que se requiere autorización estatal, la persona jurídica no puede funcionar antes de obtenerla".

Se impone, en primer lugar y respecto de las personas jurídicas de carácter privado mencionadas en el art. 148 del Código Civil y Comercial de la Nación, distinguir cuáles son aquellas que, para la adquisición de su carácter de sujetos de derecho, solo requieren la formalización de un instrumento constitutivo, como las sociedades y las simples asociaciones, de aquellas que requieren

autorización estatal para funcionar, como las asociaciones civiles (art. 169), las fundaciones (art. 193) y las sociedades cooperativas (art. 10 de la ley 20.337) y finalmente aquellas entidades en donde el carácter de sujeto de derecho nace con su inscripción registral, como las mutuales (art. 3º de la ley 20.321) o el consorcio de propiedad horizontal (art. 2038 del Cód. Civ. y Com.).

La importancia de la solución del art. 142 del Cód. Civ. y Com. radica en que, en principio, la persona jurídica no podrá realizar actos jurídicos antes de instrumentar su acto constitutivo, su inscripción registral u —según el caso— obtener su autorización para funcionar, siendo ellos inoponibles a la propia entidad. Ello, con excepción de las sociedades de hecho que, incluidas en la sección IV del capítulo I de la ley 19.550, gozan de personalidad jurídica a partir de su actuación frente a terceros, independientemente de la formalización de todo instrumento escrito de constitución, del cual carecen.

Es también importante destacar que, como hemos visto, el sistema de la autorización estatal se mantiene para casos especiales —asociaciones civiles, fundaciones y cooperativas—, lo cual implica que el Estado somete a determinadas personas de existencia ideal al ejercicio de su poder de policía, autorización que exige la previa autorización de sus estatutos y que entendemos como un requisito constitutivo de la persona jurídica.

Clasificación de las personas jurídicas

En lo que se refiere a la clasificación de las personas jurídicas efectuada por los arts. 145, 146 y 148 del Código Civil y Comercial de la Nación, debe destacarse que el art. 145, recoge la distinción universalmente reconocida entre las personas jurídicas y privadas, haciendo una enumeración de las de carácter público en el art. 146 y de las de carácter privado en el art. 148.

El art. 146 del Cód. Civ. y Com. prevé, respecto de las personas jurídicas públicas, que ellas se rigen, en cuanto a su reconocimiento, comienzo, capacidad, funcionamiento, organización y fin de su existencia, por las leyes y ordenamientos de su Constitución.

Respecto de las personas jurídicas privadas, el art. 148 hace una enumeración que incluye las siguientes: a) Las sociedades; b) Las asociaciones civiles; c) Las simples asociaciones; d) Las fundaciones; e) Las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas; f) Las mutuales; g) Las sociedades cooperativas; h) El consorcio de propiedad horizontal; i) Toda otra contemplada en disposiciones de este Código o en otras leyes y cuyo carácter de tal se establece o resulta de su finalidad y normas de funcionamiento.

El art. 149 del Cód. Civ. y Com. dispone que la participación del Estado en personas jurídicas privadas no modifica el carácter de estas.

§ 3. ATRIBUTOS Y EFECTOS DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS DE EXISTENCIA IDEAL

Generalidades

Los arts. 151 a 167 del Código Civil y Comercial de la Nación contienen una serie de disposiciones referidas a los atributos y a los efectos de la personalidad jurídica de las personas de existencia ideal, así como determinadas normas tendientes a regular su funcionamiento y su disolución y liquidación. Son todas ellas normas generales que se aplican para el caso de no existir disposiciones específicas contenidas en las leyes especiales que regulan los diversos tipos de personas jurídicas (art. 150, Cód. Civ. y Com.).

Nombre de la persona jurídica

El art. 151 se refiere al nombre de la persona jurídica, la cual debe tener una denominación que la identifique como tal con el aditamento de la forma jurídica adoptada.

Continúa prescribiendo el art. 151 del Cód. Civ. y Com. que el nombre debe satisfacer los recaudos de veracidad, novedad y aptitud distintiva, tanto respecto de otros nombres, como de marcas, nombres de fantasía u otras formas de referencia a bienes o servicios, se relacionen o no con el objeto de la persona jurídica.

Domicilio y sede social

Respecto del domicilio de las personas jurídicas, el nuevo Código receptó la normativa de la ley 19.550 en cuanto diferencia entre domicilio y sede social (art. 11, inc. 2º, LS). Dispone al respecto el art. 152 del Cód. Civ. y Com. que el domicilio de la persona jurídica es el fijado en sus estatutos o en la autorización que se le dio para funcionar. La persona jurídica que posee muchos establecimientos o sucursales tiene su domicilio especial en el lugar de dichos establecimientos solo para la ejecución de las obligaciones allí contraídas. El cambio de domicilio requiere modificación del estatuto y el cambio de sede; si no forma parte del estatuto, puede ser decidido por el órgano de administración.

El principal efecto en torno al régimen del domicilio y sede de la persona jurídica está contemplado por el art. 153 del Cód. Civ. y Com., en cuanto —en forma idéntica con lo dispuesto por el art. 11, inc. 2º, de la ley 19.550 de sociedades comerciales— dispone que se tienen por válidas y vinculantes para la persona jurídica todas las notificaciones efectuadas en la sede inscripta.

Patrimonio

El art. 154 del Cód. Civ. y Com. prevé, como principio general que la persona jurídica debe tener un patrimonio. De lo contrario, y como bien afirma la doctrina, se estaría creando una entidad sin posibilidad de realizar la finalidad propuesta, y de darse esta situación, ello implicaría la imposibilidad de la persona ideal de responder con su patrimonio ante las obligaciones contraídas, careciendo de garantía ante sus acreedores. El patrimonio de la persona jurídica está integrado por todos los bienes que ella es titular, así como las deudas que la gravan.

Plazo de duración

En lo que respecta al plazo de duración de la persona jurídica, es ilimitada en el tiempo, excepto que la ley o el estatuto dispongan lo contrario (art. 155, Cód. Civ. y Com.), lo cual es solución que resulta compatible con las entidades de bien común y no con aquellas donde los integrantes persigan fin de lucro – sociedades– y en las cuales resulta razonable la determinación de un plazo de vigencia de esa agrupación, así como la expectativa de los socios a la percepción de una cuota liquidatoria. Así lo impone el art. 11, inc. 5º, de la ley 19.550, cuando establece que todo contrato de sociedad debe contener un plazo de vigencia que debe ser necesariamente determinado.

Objeto

Finalmente, dispone el art. 156 del Código Civil y Comercial de la Nación que el objeto de la persona jurídica debe ser preciso y determinado, con lo cual y en idéntico sentido al previsto en el art. 141, limita la capacidad del ente a los actos necesarios para el cumplimiento del referido objeto. Se trata en consecuencia de una nueva remisión al principio de la especialidad o a la doctrina del *ultra vires*, que –como hemos visto ya– son totalmente congruentes con la naturaleza de la personalidad jurídica de los entes de existencia ideal.

§ 4. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

Normativa aplicable

A ellas se refieren los arts. 157 a 162 del Cód. Civ. y Com. que tratan, sucesivamente, las cuestiones referidas a la vigencia de las modificaciones del estatuto y su oponibilidad interna y externa (art. 157); las pautas para el gobierno, administración y fiscalización de la entidad (art. 158); la actuación de los administradores y su responsabilidad (arts. 159 y 160); el procedimiento para superar los obstáculos que impidan adoptar las decisiones de las personas jurídicas (art. 161) y la procedencia de la reorganización de estas a través de las figuras de la transformación, fusión y escisión (art. 162).

El estatuto y sus modificaciones

En primer lugar, dispone el art. 157 del Cód. Civ. y Com., en su párrafo inicial, que el estatuto de las personas jurídicas puede ser modificado en la forma en que él o la ley establezcan.

Dispone al respecto el art. 157: "La modificación del estatuto produce efectos desde su otorgamiento. Si requiere inscripción es oponible a terceros a partir de ésta, excepto que el tercero la conociera". De manera tal que, en las relaciones internas de la persona jurídica, esto es, entre los miembros entre sí y frente a la sociedad, la decisión del órgano correspondiente es oponible desde el momento de su adopción y obliga a los administradores a su ejecución. Por su parte, y en cuanto a los terceros, las modificaciones estatutarias son oponibles desde su

toma de razón en el registro correspondiente, salvo cuando el tercero conociera su adopción por el órgano competente, conocimiento que deberá ser acreditado por la sociedad o por sus integrantes.

Gobierno, administración y fiscalización de la persona jurídica: reuniones a distancia y autoconvocatoria del órgano de gobierno

De conformidad con lo dispuesto por el art. 158 del Cód. Civ. y Com., el estatuto debe contener normas sobre el gobierno, la administración y representación y, si la ley la exige, sobre la fiscalización interna de las personas jurídicas.

Obligaciones y responsabilidades de los administradores de personas jurídicas

En cuanto a la responsabilidad de los administradores de personas jurídicas, los arts. 159 y 160 del Cód. Civ. y Com. reproducen, en lo pertinente, lo prescrito por el art. 59 de la ley 19.550, disponiendo que los administradores de la persona jurídica deben obrar con lealtad y diligencia (art. 159, primer párrafo), respondiendo en forma ilimitada y solidaria frente a la persona jurídica, sus miembros y terceros, por los daños causados por su culpa en el ejercicio o con ocasión de sus funciones, por acción u omisión (art. 160).

Por su parte, el segundo párrafo del art. 159 reglamentando, de alguna manera, el deber de lealtad de los administradores de personas jurídicas y siguiendo los lineamientos del art. 272 de la ley 19.550 dispone que ellos no pueden perseguir ni favorecer intereses contrarios a los de la persona jurídica y si en determinada operación, los tuvieran por sí o por interpósita persona, deben hacerlo saber a los demás miembros del órgano de administración o en su caso al órgano de gobierno y abstenerse de cualquier intervención relacionada con dicha operación.

Finalmente, el último párrafo del art. 159 del Cód. Civ. y Com. prevé que les corresponde a los administradores de las personas jurídicas implementar sistemas y medios preventivos que reduzcan el riesgo de conflicto de intereses en sus relaciones con la persona jurídica.

La responsabilidad de los administradores de personas jurídicas por los daños causados en ejercicio o en ocasión de sus funciones, por acción u omisión, no libera a la persona de existencia ideal de su responsabilidad propia frente a sus miembros o terceros afectados por aquella ilegítima actuación. Así lo dispone expresamente el art. 1763 del Cód. Civ. y Com. cuando prescribe que "la persona jurídica responde por los daños que causen quienes las dirigen o administran en ejercicio o con ocasión de sus funciones", sin perjuicio, claro está, de las posteriores acciones de responsabilidad que la persona de existencia ideal pueda entablar contra quienes fueron responsables de tal conducta.

La obligación de los administradores de las personas jurídicas es de medios y no de resultados —salvo algún caso excepcional, como lo es el deber de llevar la contabilidad regular conforme a lo dispuesto por los arts.

320 a 331 del Código Civil y Comercial de la Nación—, toda vez que solamente tienen el deber de poner la diligencia, lealtad y profesionalidad necesarias para lograr el objeto de la persona jurídica, que puede no llegar a concretarse, no por mal desempeño del cargo, sino —entre otros motivos— por la adversa fortuna de los negocios.

§ 5. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

A las causales de disolución de las personas jurídicas se refiere el art. 163 del Cód. Civ. y Com., disponiendo expresamente: "La persona jurídica se disuelve:

"a) La decisión de sus miembros adoptada por unanimidad o por la mayoría establecida por el estatuto o disposición especial.

"b) El cumplimiento de la condición resolutoria a la que el acto constitutivo subordinó su existencia.

"c) La consecución del objeto para el cual la persona jurídica se formó o la imposibilidad sobreviniente de cumplirlo.

"d) El vencimiento del plazo.

"e) La declaración de quiebra; la disolución queda sin efecto si la quiebra concluye por avenimiento o se dispone la conversión del trámite en concurso preventivo o si la ley especial prevé un régimen distinto.

"f) La fusión respecto de las personas jurídicas que se fusionan o la persona o las personas jurídicas cuyo patrimonio es absorbido; y la escisión respecto de la persona jurídica que se divide y destina todo su patrimonio.

"g) La reducción a uno del número de miembros, si la ley especial exige pluralidad de ellas y esta no es reestablecida dentro de los tres meses.

"h) La denegatoria o revocación firme de la autorización estatal para funcionar, cuando ésta sea requerida.

"i) El agotamiento de los bienes destinados a sostenerla.

"j) Cualquier otra causa prevista en el estatuto o en otras disposiciones de este Título o de ley especial".

CAPÍTULO II - EL CONTRATO DE SOCIEDAD COMERCIAL. NATURALEZA DE SU ACTO CONSTITUTIVO Y ELEMENTOS DEL CONTRATO DE SOCIEDAD

§ 5. NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO CONSTITUTIVO DE LA SOCIEDAD

Nuestra legislación societaria, se enroló sin reservas en la teoría contractualista para explicar el actoconstitutivo de la sociedad, entendiendo que las diferencias que pueden existir entre la sociedad con los contratos con prestaciones contrapuestas de las partes, no justifican de manera alguna el abandono de las nociones clásicas del contrato.

La sociedad se trata de un contratode organización creado como medio de concentrar capitales para la realización de una actividad de carácter económico y a través del cual sus otorgantes disponen de un complejo de normas estructurales y funcionales destinadas a regular permanentemente las relaciones emergentes del negocio jurídico constitutivo. *Por ello, la opinión*

predominante dentro de la doctrina nacional y extranjera es que el negocio jurídico por cuya virtud se crea una sociedad es un contrato plurilateral de organización.

§ 6. CARACTERES DEL CONTRATO DE SOCIEDAD

Partiendo de la base de que, salvo el especial caso de la sociedad unipersonal, la sociedad es un contrato, sus caracteres son:

a) *Es consensual*, pues basta el consentimiento de los otorgantes para hacer nacer los derechos y obligaciones que se derivan del carácter de socios, así como para generar los efectos característicos del contrato.

b) *Es conmutativo*, pues al momento de constituir la sociedad las partes pueden conocer las ventajas y sacrificios que el negocio ofrece. El alea común, que se traduce en la existencia de ganancias o pérdidas, es propio de cualquier contrato y no exclusivamente del contrato de sociedad.

c) *Es oneroso*, porque no es concebible que una persona pueda adquirir los derechos de socio si no cumple con la necesaria aportación al fondo común.

d) *Es de ejecución continuada o duradera*, pues el contrato de sociedad no se celebra para una sola operación sino para realizar actividades y generar con ellas ganancias a sus socios que, como principio general, se liquidarán anualmente en la medida en que existan ganancias realizadas y líquidas que surjan de los estados anuales de la compañía.

e) *Es, en principio, plurilateral*, porque el contrato de sociedad ha sido pensado como instrumento de concentración de capitales y alberga a un número ilimitado de socios, debiendo contar siempre con no menos de dos de ellos, salvo el caso de las sociedades anónimas unipersonales, en donde basta la declaración unilateral de voluntad para crearla.

f) *Es un contrato de organización*, pues a diferencia del contrato, que presupone un intercambio de prestaciones que se agotan con su realización, en la sociedad cada parte constituye, a través de prestaciones coordinadas, el patrimonio de un nuevo sujeto de derecho creado en virtud del contrato a través del cual los socios obtendrán los beneficios esperados. Por otra parte, el carácter organizacional del acto constitutivo de la sociedad surge de la necesidad de reglamentar, en el contrato social o estatuto, las relaciones entre los socios y de estos con la sociedad, así como el funcionamiento del ente, desde su punto de vista interno como frente a los terceros.

§ 8. ELEMENTOS DEL CONTRATO DE SOCIEDAD

Aclarada ya la adhesión por la ley 19.550 a la teoría contractualista del acto constitutivo de la sociedad, bien que, dentro de la categoría de los contratos plurilaterales de organización, no puede ser objeto de discusión la necesidad de reunir en el contrato de sociedad los elementos comunes a todo contrato, esto

es, consentimiento, capacidad, objeto y causa, a los cuales les resultan aplicables en términos generales las normas del ordenamiento común.

§ 9. OBJETO DEL CONTRATO DE SOCIEDAD

El objeto del contrato de sociedad no debe ser confundido con el objeto social. Aquel está constituido por las prestaciones de dar o de hacer que se comprometieron a efectuar los socios y que constituyen a su vez el objeto de las obligaciones originadas en el contrato de sociedad (arts. 1003 a 1011, Cód. Civ. y Com.). El objeto social, que es requisito de inclusión esencial en todo contrato de sociedad, por expresa directiva del art. 11, inc. 3º, de la ley 19.550, consiste en el ámbito de las actividades económicas delimitadas en el contrato o acto constitutivo.

§ 10. LA CAUSA DEL CONTRATO DE SOCIEDAD

La causa del contrato de sociedad es la finalidad que han tenido los fundadores para su constitución, y no es otra que la obtención de las ganancias a través de la realización de las actividades previstas en el contrato social.

§ 11. ELEMENTOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO DE SOCIEDAD

Los elementos específicos del contrato de sociedad comercial se encuentran previstos en la definición que de él nos brinda el art. 1º de la ley 19.550, que dispone textualmente: "Habrá sociedad comercial cuando una o más personas en forma organizada, conforme a uno de los tipos previstos en esta ley, se obliguen a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios participando de los beneficios y soportando las pérdidas".

Los elementos específicos del contrato de sociedad comercial son, pues, los siguientes: la organización, la tipicidad, los aportes, el fin societario y la participación en los beneficios y soportación en las pérdidas, debiendo recordarse que, con anterioridad a la sanción de la ley 26.994, era también un elemento específico del contrato de sociedad la pluralidad de socios. Analizaremos cada uno de ellos a continuación.

Pluralidad de socios. Las sociedades de un solo socio

Hasta la sanción de la ley 26.994, del 7 de octubre del 2014, la pluralidad de socios ("dos o más") era una de las características más importantes del contrato de sociedad, pero ello aconteció hasta la admisión de las sociedades unipersonales por dicha ley, y si bien actualmente la ley 19.550 ha limitado la actuación y constitución de las sociedades de un solo socio a numerosas restricciones, lo cierto es que mal podemos hoy afirmar que la pluralidad de socios constituya un requisito esencial del contrato de sociedad.

De modo tal que las sociedades unipersonales exhiben hoy las siguientes las principales características:

a) Solo se permite que sean sociedades unipersonales las sociedades anónimas (art. 1º).

b) La sociedad unipersonal solo puede ser constituida por instrumento público y por acto único (art. 165).

c) No puede ser único socio otra sociedad unipersonal (art. 1º).

d) La denominación debe ser "sociedad anónima unipersonal", su abreviatura o sigla "SAU" (art. 164). La integración del aporte debe efectuarse en su totalidad al momento de su constitución (art. 187).

e) La reducción a uno del número de socios de las sociedades anónimas no unipersonales no conforma una causal de disolución de dichas compañías (art. 94 bis), sino que deben adecuar la denominación social a la exigencia del art. 164 para las sociedades unipersonales y cumplir con el régimen dispuesto por el art. 299, siempre de la ley 19.550.

f) Están sujetas a la fiscalización estatal permanente (art. 299).

g) Deben publicar los edictos de convocatoria a las asambleas por cinco días en el Boletín Oficial y en otro diario de amplia circulación en la República Argentina (art. 237).

La tipicidad

El art. 1º de la ley 19.550 ha insistido en el concepto de tipicidad, en virtud del cual los constituyentes de la sociedad no pueden apartarse de los tipos creados por el legislador si pretenden tener una sociedad regularmente constituida. Se ha entendido, en defensa de la tipicidad, y estoy de acuerdo con ello, que brinda seguridad al tráfico mercantil, pues los terceros saben, cuando contratan con una determinada sociedad comercial, cuál es el alcance de la responsabilidad de los socios, quién se encuentra facultado para representarla y cuáles son, en definitiva, las pautas de su funcionamiento interno.

La organización

El concepto de "organización" al que refiere el art. 1º de la ley 19.550 está referido a la realización por el ente de una actividad mercantil de producción o intercambio de bienes o servicios.

Los aportes

La realización de los aportes constituye un requisito de la existencia misma del contrato de sociedad, de modo tal que sin aportes no puede haber socios y, por ende, tampoco sociedad, pues esta es onerosa por naturaleza. El aporte es la contribución de cada socio al fondo común que debe constituirse para el desarrollo del objeto social, y el conjunto de los aportes, en dinero o en especie, estimados en una cifra determinada, forman el capital social de la compañía.

Los aportes pueden transferirse a la sociedad en propiedad o en uso y goce, según se convenga. Asimismo, pueden consistir en dinero, créditos a cargo de terceros, cosas muebles e inmuebles, mercaderías, patentes de invención, marcas de fábrica o de comercio, fondos de comercio, trabajos personales e incluso bienes sometidos a gravámenes, pero no todas esas prestaciones

pueden ser aportadas a cualquier tipo social, pues tratándose de sociedades en donde los socios limitan su responsabilidad al aporte efectuado y los terceros no cuentan con la posibilidad de agredir el patrimonio de los socios por las obligaciones sociales, es lógico que la ley 19.550 imponga para estas sociedades que los aportes solo pueden consistir en dinero o en prestaciones de dar, susceptibles de ejecución forzada.

La producción o intercambio de bienes o servicios. El fin societario

La definición que nos brinda el art. 1º de la ley 19.550 impone asimismo que la sociedad comercial debe dedicarse a la producción o intercambio de bienes o servicios, lo cual constituye su "fin societario".

La participación en los beneficios y soportación de las pérdidas

Finalmente, la definición de sociedad comercial prevista en el art. 1º de la ley 19.550 incluye al fin común o a la causa del contrato de sociedad, que se traduce en la obtención de beneficios económicos, denominados técnicamente dividendos, debiendo los socios soportar las pérdidas sufridas por la sociedad.

Es necesario aclarar que la participación en los beneficios está sujeta a un procedimiento especial previsto expresamente por la ley 19.550 en sus arts. 68 y 224, pues los administradores no pueden repartir las ganancias en cualquier momento o de cualquier manera, como es propio en las sociedades de profesionales, sino que los dividendos solo pueden ser aprobados y distribuidos a los socios si ellos surgen de ganancias realizadas y líquidas resultantes de un balance confeccionado de acuerdo con la ley y el estatuto y aprobado por el órgano social competente, salvo en las sociedades anónimas incluidas en el art. 299 de la ley 19.550.

Los socios deben pactar en el contrato constitutivo o en el estatuto la forma cómo se distribuirán las ganancias obtenidas por la sociedad. Caso contrario, la distribución se hará en proporción a los aportes (art. 11, inc. 7º, ley 19.550), pero son nulas de nulidad absoluta las cláusulas del contrato social o estatuto por medio de las cuales alguno o algunos de los socios reciban todos los beneficios o se los excluya de ellos, o que sean liberados de contribuir a las pérdidas, que le aseguren al socio su capital o las ganancias eventuales o que la totalidad de las ganancias pertenezcan al socio o socios sobrevivientes. Tales estipulaciones han sido denominadas "cláusulas leoninas" y su invalidez está impuesta expresamente en el art. 13 de la ley 19.550.

En cuanto a las pérdidas, ellas serán soportadas de acuerdo con el tipo social adoptado. Si se trata de una sociedad de las incluidas en la categoría de "sociedades de personas" o "sociedades por parte de interés", los socios responden en forma solidaria e ilimitada por las obligaciones contraídas por la sociedad, previa excusión de los bienes sociales. Si se trata de una sociedad de capital, categoría dentro de la cual he incluido a las sociedades de responsabilidad limitada y a las sociedades por acciones, las únicas pérdidas que los socios o accionistas deben soportar se limitan a los fondos oportunamente aportados a la sociedad.

En todos los casos, el contrato social o estatuto debe establecer las reglas para la soportación de las pérdidas por parte de los socios, y en caso de silencio y al igual que las ganancias, serán soportadas en proporción a los aportes efectuados. Pero si el contrato social o estatuto previeron la forma de distribuir las ganancias y no las pérdidas, estas deberán soportarse en la misma proporción (art. 11, inc. 7º, ley 19.550).

La *affectio societatis*

Varias son las definiciones que se han dado de la conocida *affectio societatis* que constituye un elemento específico del contrato de sociedad: voluntad de cada socio de adecuar su conducta y sus intereses personales, egoístas y no coincidentes a las necesidades de la sociedad; disposición anímica de colaboración en todo lo que haga al objeto de la sociedad; relación vinculada a la existencia de una voluntad común de los socios para la consecución del fin social y constituida más bien por una disposición anímica activa de colaboración en todo lo que haga al objeto de la sociedad, etcétera.

En definitiva, la *affectio societatis* es la predisposición de los integrantes de la sociedad de actuar en forma coordinada para obtener el fin perseguido con su constitución, postergando los intereses personales en aras del beneficio común.

CAPÍTULO III - LA UNIFICACIÓN DEL DERECHO PRIVADO Y SU INFLUENCIA EN LA LGS. DIFERENCIA DE LA SOCIEDAD CON OTROS CONTRATOS ASOCIATIVOS. CLASIFICACIÓN DE LAS SOCIEDADES

§ 12. EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN. LAS MODIFICACIONES EFECTUADAS POR LA LEY 26.994

Como consecuencia de la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación por la ley 26.994 y la derogación de las normas del Código Civil y del Código de Comercio, se unificó nuestro derecho privado, cumpliéndose de esa manera con un viejo anhelo de cierta parte de la doctrina nacional.

Lo cierto es que hoy la República Argentina puede exhibir un derecho privado unificado y un régimen societario casi único, plasmado en la ahora denominada Ley General de Sociedades, que comprende tanto a las sociedades comerciales como civiles, que se rigen por las normas de la ley 19.550.

§ 14. CLASIFICACIÓN DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES

Una primera clasificación de las sociedades comerciales nos obliga a distinguir entre las sociedades constituidas regularmente de aquellas que no han cumplido los requisitos de forma y publicidad exigidas por la ley 19.550.

Las primeras son conocidas como *sociedades regulares* por haber adoptado uno de los tipos previstos por la mencionada ley, cumplido con las formas y con

la publicidad requerida por el ordenamiento societario e inscriptas en el Registro Público. Las segundas, conocidas como *sociedades irregulares y/o sociedades de hecho* fueron legisladas por la ley 19.550 en su versión original en una sección denominada "De la sociedad no constituida regularmente" (sección IV del capítulo I, arts. 21 a 26), aunque actualmente, y como consecuencia de las reformas efectuadas por la ley 26.994, ellas pasaron a integrar el listado de las sociedades mencionadas en el reformado art. 21 que se someterán a las disposiciones de esta sección, esto es, las sociedades que no se constituyeron con sujeción a los tipos previstos en el capítulo II de la ley 19.550, que omitan requisitos esenciales o que incumplan con las formalidades exigidas por la ley. Se trata de sociedades que han sido reguladas como integrando una categoría o clase de sociedades por lo general viciadas en su forma y sometidas a un régimen único, cualquiera que haya sido el tipo que los constituyentes hayan querido adoptar.

La aludida reforma convierte a las sociedades incluidas en esta sección en una especie de tipo social, en el cual sus integrantes responden ante terceros en forma mancomunada y por partes iguales, pudiendo oponerse entre sí, ante la sociedad y frente a terceros, las cláusulas del contrato social. Podemos pues afirmar que las drásticas diferencias existentes entre las sociedades regulares e irregulares hasta la sanción de la ley 26.994 perdió gran parte de su trascendencia, sin olvidar que las hoy denominadas "Sociedades de la sección IV" no son un tipo social sino una clase de sociedades, que no pueden acceder a ninguno de los procedimientos para los cuales la ley 19.550 prevé la existencia de tipicidad para sus integrantes (arts. 74, 82, 88 y 90, LGS).

Realizada esa primera clasificación, deben efectuarse las siguientes distinciones entre las sociedades regulares, esto es, entre aquellas que se han adaptado a uno de los tipos previstos en el capítulo II de la ley 19.550 o en otros cuerpos normativos.

El legislador de la ley 19.550 ha intentado, aunque con muy poco éxito, mantener dentro de la regulación de los distintos tipos societarios una correlación y adecuación entre la estructura técnica de cada sociedad y la realidad económica en que ella se desenvuelve, y en tal sentido ha distinguido entre las denominadas **sociedades de interés, las sociedades por cuotas y las sociedades por acciones.**

1. Entre las **sociedades de interés** se cuentan las sociedades colectivas, de capital e industria y en comandita simple. Son sociedades que cuentan por lo general con muy pocos socios y se caracterizan fundamentalmente, dejando de lado por ahora las particularidades de cada una de ellas, por la responsabilidad solidaria e ilimitada, aunque subsidiaria de sus integrantes, así como por un esquema sencillo de funcionamiento. Es también característica de estas sociedades la enorme relevancia de la personalidad de los socios, y de ello se deriva la necesidad de obtener la conformidad de los restantes socios para la cesión de la parte de interés por uno de ellos, así como también el riguroso sistema de mayorías previsto a los fines de modificar el contrato social. Por ello, este tipo de sociedades es también conocido como *sociedades de personas*.

Dentro de las sociedades por parte de interés o sociedades de personas, se encuentran las siguientes:

a) Las sociedades colectivas: Son el paradigma de las sociedades por parte de interés. Todos sus socios responden en forma solidaria e ilimitada por las obligaciones sociales, aun cuando ellos cuentan con el derecho de exigir a los acreedores la agresión prioritaria del patrimonio societario (beneficio de excusión). Su normativa (arts. 125 a 133) es aplicable a las demás sociedades incluidas en esta clasificación, en lo que le resultaran compatibles.

b) Las sociedades en comandita simples: Se caracterizan por la existencia de dos categorías de socios; los socios comanditados o solidarios, que responden como los socios de las sociedades colectivas, y los socios comanditarios, que responden solamente por los aportes efectuados a la sociedad, que deben necesariamente consistir en obligaciones de dar. Precisamente por los límites de la responsabilidad asumida, les está prohibido a estos socios ejercer la administración de la sociedad, la cual deberá estar a cargo de los socios comanditados o terceros (arts. 134 a 140, ley 19.550).

c) Las sociedades de capital e industria: También se caracterizan por la existencia de dos categorías de socios: los socios capitalistas, que responden de los resultados de las obligaciones sociales como los socios de la sociedad colectiva, y los socios industriales, que responden hasta la concurrencia de las ganancias no percibidas. A diferencia de las sociedades en comandita simple, la administración de las sociedades de capital e industria puede ser desempeñada por cualquiera de los socios, no estando vedada a los socios industriales (arts. 141 a 145, ley 19.550).

Huelga manifestar que estos tipos de sociedades no tienen hoy, por diversos motivos, la menor aceptación, pues la imposibilidad de limitar la responsabilidad por los riesgos empresarios y la posibilidad de que los acreedores sociales puedan agredir el patrimonio particular de los integrantes de dichas personas jurídicas torna su constitución absolutamente desalentadora.

2. Las **sociedades por "cuotas"** son exclusivamente las sociedades de responsabilidad limitada, caracterizadas por la división de su capital social en cuotas de igual valor y la responsabilidad de todos sus socios por las cuotas que hubieran suscripto e integrado.

Las **sociedades de responsabilidad limitada**, incorporadas a nuestra legislación societaria en el año 1932 (ley 11.645), fueron objeto de modificaciones por la ley 19.550 para intentar cubrir el campo de actividades económicas que considere inadecuado adaptarse al esquema más complejo de la sociedad anónima. Si bien originalmente pudieron incluirse a estas sociedades dentro de una categoría mixta, intermedia entre las sociedades de personas y las sociedades de capital, la actual regulación de las sociedades de responsabilidad limitada efectuada por la ley 22.903 del año 1982 las acerca mucho más a las sociedades de capital, resultando cada vez más indiferente la personalidad de sus integrantes (arts. 146 a 162).

3. Finalmente, las **sociedades por acciones** son aquellas sociedades en las cuales su capital social se divide en acciones que se incorporan a títulos representativos, y así circulan. Sus socios, denominados accionistas, limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscriptas. Se

incluyen dentro de las sociedades por acciones a los siguientes tipos y subtipos:

a) **La sociedad anónima**: Es la sociedad por acciones por naturaleza y de enorme trascendencia para el desarrollo de la economía. Sus características son la división total de su capital en acciones, así como la limitación de la responsabilidad de los socios a la integración de las acciones suscriptas por estos (arts. 163 a 314).

b) Las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria: Legisladadas en los arts. 308 a 314 de la ley 19.550. En puridad se trata de un subtipo de las sociedades anónimas, pues su característica es la presencia del Estado nacional, Estados provinciales, municipales u organismos estatales autorizados al efecto como titulares en forma individual o conjunta de acciones que representan el 51% del capital social y que sean suficientes para prevalecer en las asambleas ordinarias y extraordinarias.

c) Sociedades en comandita por acciones: Tienen, al igual que las sociedades en comandita simple, dos tipos de socios: a) los socios comanditarios que tienen las mismas características que los accionistas de las sociedades anónimas, y b) los socios solidarios o comanditados, que responden en forma solidaria. La diferencia que existe entre ambas comanditas radica en la titularidad de los socios comanditarios de títulos accionarios (arts. 315 a 324, ley 19.550).

d) Las sociedades de economía mixta: No se encuentran contempladas por la ley 19.550, sino por la ley 12.962, ratificatoria del dec. 15.349/1946. Se distinguen de las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria en el sentido de que en estas el interés del Estado no necesariamente debe ser superior al capital privado.

e) Las sociedades por acciones simplificadas (SAS): Estas sociedades se encuentran insólitamente legisladas en la ley 27.349 de apoyo al capital emprendedor, sancionada en el año 2017.

f) Las sociedades cooperativas: Se encuentran reguladas por la ley 20.337 y son sociedades de capital variable, con acciones nominativas, cuyo fin principal consiste en crear ventajas económicas a sus asociados y no utilidades apreciables en dinero. Son sociedades comerciales y se les aplican supletoriamente las normas de la ley 19.550.

g) Las sociedades de garantía recíproca (SGR): Incorporadas a nuestra legislación mercantil por la ley 24.467 y cuyo único y exclusivo objeto consiste en prestar garantías en favor de sus socios partícipes para las operaciones que estos realicen dentro del giro ordinario de sus empresas.

§ 15. EL TIPO SOCIETARIO Y LA MAGNITUD DE LA EMPRESA

Como hemos expuesto, el legislador societario de 1972 procuró proporcionar formas técnicas adecuadas para actividades económicas de diferente importancia y características, y es por ello que intentó reservar el molde de las sociedades de personas a las pequeñas empresas, dejando a las sociedades de

responsabilidad limitada para cubrir un campo de actividades que consideró inadecuado para adaptarse al esquema más complejo de la sociedad anónima, que destinó para los grandes emprendimientos.

La legislación reservada a cada uno de los tipos sociales fue coherente con esa intención del legislador, pues en las sociedades de interés o de personas el esquema de funcionamiento es sumamente sencillo, así como promiscuo el régimen de administración toda vez que la constitución de estas sociedades reposa en la confianza que debe existir entre sus integrantes. En las sociedades anónimas sucede todo lo contrario, pues su legislación es muy extensa y minuciosa, reglamentando detalladamente la ley 19.550 el funcionamiento de sus órganos de administración, gobierno y fiscalización, y asegurando el legislador, a cada uno de los accionistas, a través de normas inderogables, el ejercicio de sus derechos esenciales.

La realidad de los negocios traicionó el fin docente del legislador, pues los comerciantes o empresarios no reparan en otra cosa, al momento de iniciar sus actividades mercantiles en sociedad, que la posibilidad de limitar su responsabilidad patrimonial en la menor forma posible y tal elemental realidad convirtió a las sociedades por parte de interés casi en una curiosidad legislativa, siendo solo utilizadas cuando alguna normativa legal imponga a determinado emprendimiento comercial la utilización de estos tipos societarios, como ocurrió en nuestro país con la actividad farmacéutica, que debió desarrollarse durante muchísimos años a través de las sociedades en comandita simple, sistema que sigue parcialmente vigente en la provincia de Buenos Aires para la referida actividad.

Al igual que sucede en otros países, como, por ejemplo, en España, la sociedad anónima es el molde o tipo societario bajo el cual se constituyen todos o casi todos los emprendimientos empresarios, y lo que debió estar reservado a los grandes negocios, como lo es el minucioso y detallista régimen legal de las sociedades anónimas, es utilizado hasta por el comerciante minorista, a quien poco le interesa la complejidad del funcionamiento de estas sociedades, que por lo general no es respetado. Puede sostenerse que este previsible fenómeno no fue ignorado por la ley 19.550 que dividió a las sociedades anónimas en "abiertas" y "cerradas", simplificando de alguna manera el funcionamiento de estas últimas, pero ello no fue suficiente, *pues la realidad ha demostrado que en puridad, la gran mayoría de las sociedades anónimas que funcionan en nuestro medio son sociedades colectivas disfrazadas de sociedades anónimas*, lo que constituye una fuente inagotable de conflictos.

Las sociedades de responsabilidad limitada constituyen un verdadero enigma que todavía no ha podido ser descifrado. Nacieron en nuestro país en el año 1932, cubriendo un importante vacío legal, en épocas en que regía el Código de Comercio que imponía para constituir una sociedad anónima la necesidad de contar con diez accionistas como mínimo y obtener autorización del Poder Ejecutivo, que era el punto de partida de su reconocimiento como sujeto de derecho. La sociedad de responsabilidad limitada brindó la posibilidad para todos los socios de limitar su responsabilidad por los riesgos empresarios, sin menoscabo del elemento personal propio de las sociedades de personas. Por ello, no sorprendió que hasta la vigencia de la ley 19.550 en el año 1972, el molde de las sociedades de responsabilidad limitada tuviera gran aceptación.

Sin embargo, sancionada la ley 19.550 y eliminados los requisitos de la autorización del Poder Ejecutivo, así como el número mínimo de diez accionistas para la constitución de una sociedad anónima, las sociedades de responsabilidad limitada perdieron parte de su atractivo, pues si de responsabilidad de los socios se trataba, el régimen de la sociedad anónima era más benigno, porque no existía para estas la responsabilidad solidaria e ilimitada de todos los socios por la falta de integración de los aportes dinerarios o por la sobrevaluación de los bienes en especie que el legislador (art. 150, ley 19.550) había impuesto para todos los integrantes de las sociedades de responsabilidad limitada.

La ley 22.903 de 1982, que reformó la ley 19.550, con el propósito de alentar la constitución de las sociedades de responsabilidad limitada y hacerla más flexible e interesante, eliminó la triple división establecida por el texto original de dicha normativa, sometiéndolas a un régimen legal único, suavizando el régimen de mayorías y previendo para estas sociedades nuevas formas de adoptar acuerdos sociales sin necesidad de reunión por parte de los socios. Sin embargo, y más allá de los gravísimos errores en que incurrió la ley 22.903, como, por ejemplo, la necesidad de contar con el voto unánime para la reforma del contrato social cuando uno de los socios representare el voto mayoritario (art. 160, párr. 2º, ley 19.550) o la deficiente regulación del derecho de receso, lo cierto es que tales modificaciones no tuvieron el éxito esperado y las sociedades de responsabilidad limitada no pudieron abarcar el campo de actividades propias de las pequeñas o medianas empresas, a cargo de las sociedades anónimas. En la actualidad, se advierte un mayor interés en la constitución de sociedades de responsabilidad limitada por el hecho de que la autoridad de control ha establecido un régimen de constitución en el plazo de 24 horas, plazo en el cual dicha sociedad debe estar registrada. Si el plazo de duración del trámite de una persona jurídica constituye el elemento dirimente para la elección del tipo societario adecuado para un emprendimiento empresario, lo cierto es que la seguridad jurídica está en graves problemas, pues se sacrifica el necesario control de legalidad de la nueva persona jurídica a cargo de la autoridad de control en el altar de la celeridad, que nada bueno presagia fundamentalmente para los terceros que se habrán de vincular con la sociedad.

La única manera de poner fin a este estado de cosas es imponer un importante capital mínimo a las sociedades anónimas como requisito de constitución y de funcionamiento. Bien es cierto que el actual art. 186 de la ley 19.550 ha fijado un capital social mínimo para las sociedades anónimas de \$100.000, pero este es manifiestamente insuficiente, como lo es, sin lugar a dudas, el capital social mínimo de una sociedad por acciones simplificada que comprende el valor de dos veces el salario mínimo vital y móvil (art. 40 de la ley 27.349), que al mes de enero de 2019 asciende a la suma de \$22.600, lo cual es un verdadero desatino, pues si el capital social suficiente es la contrapartida necesaria de la limitación de la responsabilidad de los socios, la suma de \$22.600 es una burla a la seguridad jurídica.

Con otras palabras: si el objetivo de las sociedades anónimas lo constituye la concentración de capitales para la realización de emprendimientos empresarios de envergadura, su capital social debe ser importante, lo cual además redundará en beneficio de los terceros, atento a la función de garantía que el capital social

de las sociedades anónimas desempeña. Por el contrario, si se insiste en sumas que son accesibles para cualquier comerciante, no debe extrañar a nadie que se recurra a las sociedades anónimas para cualquier cosa.

§ 16. DIFERENCIAS DEL CONTRATO DE SOCIEDAD CON OTROS ACTOS O CONTRATOS ASOCIATIVOS

Sociedades y asociaciones civiles

La diferencia surge de la mera compulsa de la ley 19.550 que rige a las sociedades con los arts. 168 a 192 del Cód. Civ. y Com. y que gobierna a las asociaciones civiles.

Las diferencias son las siguientes:

a) En lo que concierne al fin de bien común o el interés general que inspira a las asociaciones civiles, las sociedades tienen por el contrario un fin lucrativo que resulta incompatible con el objetivo de las asociaciones.

b) En cuanto al capital, pues mientras en las sociedades este se constituye con el aporte de los socios, en las asociaciones civiles no existe capital aportado por los asociados, quienes se limitan al pago de una cuota social fijada por el estatuto o la asamblea y que les da derecho a utilizar los servicios que brinda la asociación. Como bien lo explica Cracogna, en las asociaciones civiles el capital no se halla individualizado en su composición, sino que es el resultado de la diferencia entre el activo y el pasivo y por lo tanto es eminentemente variable.

c) Una tercera diferencia la constituye el destino del patrimonio en caso de disolución, pues en las sociedades, una vez realizado el activo, cancelado el pasivo y reintegrado el capital aportado por los socios, el remanente se les entrega, según como fuera convenido en el contrato social. En las asociaciones civiles, el destino del remanente se orienta necesariamente hacia un fin de bien común o al Estado.

d) Asimismo, en la sociedad la formación de la voluntad social se realiza en función del capital y por ello los socios participan con una cantidad de votos proporcional al capital aportado. Ello no sucede de la misma manera en las asociaciones civiles, donde todos los asociados tienen igual derecho de voto.

e) En las asociaciones civiles, la calidad de asociado es intransferible, mientras que para las sociedades comerciales rige el principio exactamente contrario.

f) Salvo las sociedades enumeradas en el art. 299 de la ley 19.550, ellas no están sometidas al control estatal permanente. Las asociaciones civiles, por el contrario, requieren autorización para funcionar y se encuentran sujetas al control permanente de la autoridad competente, nacional o local, según corresponda.

Sociedad y fundación

La fundación es un patrimonio afectado a un objetivo de bien común o a una determinada finalidad altruista. En la fundación no hay asociados, sino un conjunto de bienes aportados por el o los fundadores y puestos al servicio de aquellos objetivos.

CAPÍTULO IV - REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATO DE SOCIEDAD COMERCIAL

§ 17. EL NOMBRE SOCIETARIO

El nombre de la sociedad es el atributo de su personalidad que la individualiza y la distingue del conjunto de los socios, quedando obligada cuando quien la representa lo hace bajo la designación de su nombre societario. Su inclusión en el contrato constitutivo de cualquier tipo social es dato exigido por el art. 11, inc. 2º, de la ley 19.950 y su omisión somete a la sociedad a las normas de la sección IV del capítulo I de la ley 19.550 (arts. 21 a 26).

§ 18. NOMBRE SOCIETARIO Y NOMBRE COMERCIAL

El nombre de la sociedad no puede ser confundido con el nombre comercial. Este es un elemento del fondo de comercio que identifica el establecimiento industrial o comercial en el ámbito del tráfico mercantil y como tal constituye un derecho patrimonial del comerciante. El nombre social es un atributo de la personalidad jurídica del que la sociedad goza, por expresa directiva legal, y por ello su régimen jurídico es sustancialmente diferente. Valgan para ilustrar lo expuesto las siguientes diferencias:

a) La propiedad del nombre comercial se adquiere por el uso y solo con relación al ramo en el que se utiliza, uso que debe ser público y ostensible para que llegue al público en general. Por el contrario, el nombre societario es inherente a la sociedad y constituye una estipulación necesaria del contrato constitutivo a los efectos de la identificación de la persona jurídica.

b) El nombre comercial es transmisible con el fondo de comercio, mientras que el nombre societario es intransmisible por su propia naturaleza.

c) El nombre comercial puede modificarse libremente por su titular mientras que deben mediar razones de excepción que justifiquen el cambio del nombre societario.

§ 21. EL DOMICILIO SOCIAL. DOMICILIO Y SEDE SOCIAL

Constituye otro de los requisitos específicos del contrato de sociedad exigido por el art. 11, inc. 2º, de la ley 19.550. El contrato social o estatuto puede limitarse a expresar la ciudad o población en que la sociedad tiene su domicilio, si los socios no quieren que la dirección constituya una cláusula contractual.

De manera tal que, si la dirección precisa constituye cláusula del contrato social o estatuto, su modificación implicará necesariamente reforma de tales instrumentos. Pero como tal dato no es necesario, el contrato social o estatuto puede limitarse a expresar la jurisdicción (ciudad o población) donde la

sociedad tiene su domicilio, y en caso de mudanza dentro de la misma jurisdicción, no será necesario reformar aquellos instrumentos.

§ 23. EL CAPITAL SOCIAL

El capital social se forma inicialmente con los aportes de los socios y debe ser adecuado al objeto que la sociedad pretenda desarrollar. La importancia del capital social está fuera de toda discusión, pues además de servir como fondo patrimonial para la obtención de beneficios a través del ejercicio por la sociedad de una determinada actividad empresarial (función de productividad) o como parámetro para medir matemáticamente la participación del socio en la sociedad, cumple una trascendentalísima función de garantía frente a los terceros, en especial en las sociedades de responsabilidad limitada y en la sociedad anónima, donde los accionistas limitan su responsabilidad a las cuotas o acciones suscriptas, porque la cifra capital brinda a los terceros un dato de fundamental importancia al permitirles conocer los bienes con que cuenta la sociedad para afrontar con sus obligaciones. De allí que prácticamente todas las legislaciones exigen a las sociedades anónimas un capital social mínimo, que debería ser adecuado al giro empresarial.

Precisamente, por la función de garantía que el capital social cumple frente a terceros, es que el legislador ha establecido una serie de normas para asegurar su intangibilidad, imponiendo la necesaria intervención de la autoridad de control en la valuación de los bienes en especie aportados a sociedades por acciones, prohibiendo la emisión de acciones por debajo de su valor nominal, impidiendo la distribución de ganancias sin un balance que compruebe su existencia o efectuando similar prohibición cuando han existido pérdidas en los anteriores ejercicios, que deben ser cubiertas con las ganancias obtenidas con posterioridad, con carácter prioritario a su distribución (arts. 53, 68, 71, 202, 224, etc.).

Si bien el capital social reviste mucho más importancia en las sociedades de responsabilidad limitada y en las sociedades por acciones, atento a la ausencia de responsabilidad subsidiaria de los socios por las obligaciones sociales, ello no significa que en las sociedades por parte de interés el capital social carezca de trascendencia, no solo por las demás funciones que cumple dicho capital (función de productividad y de medición de la participación del socio), sino porque la función de garantía tampoco está ausente en los otros tipos sociales.

§ 24. CAPITAL SOCIAL Y PATRIMONIO

Ambos son conceptos que, en el derecho de las sociedades, no pueden ser materia de confusión.

El capital social está constituido por el conjunto de los aportes de los socios integrados en el acto constitutivo o en oportunidad de su ampliación o incremento, acto que está sometido a estrictas formalidades legales. Es decir, que el capital de la sociedad es en principio fijo e invariable, salvo las modificaciones dispuestas por los socios en virtud de resoluciones societarias de aumento o reducción. Por el contrario, el patrimonio de la sociedad, cuyo monto

solo puede coincidir con el del capital social en el momento de la constitución de la sociedad, es esencialmente variable, pues el patrimonio social va cambiando y modificándose permanente y automáticamente por el giro ordinario de los negocios.

§ 25. LOS APORTES. IMPORTANCIA. BIENES APORTABLES

La mención de los aportes constituye no solo un requisito específico del contrato de sociedad comercial, según exigencia del art. 11, inc. 4º, de la ley 19.550, sino que es, como hemos visto, el objeto de dicho contrato, sin los cuales no puede haber socios, ni por ende sociedad. Debe recordarse que el capital social se forma inicialmente con los aportes de los socios y que sin aquel no existe la más mínima posibilidad de desarrollar el objeto de la sociedad.

§ 35. EL OBJETO SOCIAL

El objeto social está constituido por los actos o categorías de actos que por el contrato constitutivo podrá realizar la sociedad para lograr su fin mediante su ejercicio o actividad.

Dichos actos o categoría de actos deben encuadrar en la definición que hace el art. 1º de la ley 19.550 de sociedad comercial, cuando se refiere a la "producción o intercambio de bienes o servicios" y que comprende todas las gamas de la actividad patrimonial.

El objeto social debe reunir los siguientes requisitos:

a) Debe ser lícito, así como también deben ser lícitas las actividades tendientes a realizarlo. La sociedad de objeto ilícito se encuentra fulminada de nulidad a tenor de lo dispuesto por el art. 18 de la ley 19.550.

b) Debe ser fácticamente posible. Si la imposibilidad es preexistente y absoluta, la sociedad es nula (art. 279, Cód. Civ. y Com.); si la imposibilidad es sobreviniente, ella provocará la disolución del ente (art. 94, inc. 4º, ley 19.550).

c) Debe ser preciso y determinado. Con ello se pretende que el objeto sea enunciado con claridad y exactitud, como lo ordena el art. 11, inc. 3º, de la ley 19.550.

El objeto social tiene relevancia a los siguientes fines: a) Constituye instrumento de protección del derecho de los socios al dividendo, evitando que los fondos sociales sean afectados a otras actividades no incluidas en el objeto de la sociedad. b) Determina cuáles son las actividades en competencia que no pueden realizar los socios y los administradores en las sociedades de interés (art. 133, ley 19.550) y los administradores de todos los tipos sociales. Del mismo modo, delimita el interés contrario de unos y otros (arts. 248 y 272, ley 19.550) o los contratos que los administradores pueden celebrar con la sociedad que administran (art. 271, ley 19.550).

§ 36. OBJETO SOCIAL Y ACTIVIDAD

Si bien el objeto social solo puede cumplirse a través del desarrollo de una actividad permanente, no deben confundirse los conceptos de "objeto social" y "actividad de la sociedad" que han sido cuidadosamente distinguidos por la ley 19.550 en sus arts. 18 y 19. El objeto social delimita en el contrato constitutivo la categoría de actos que la sociedad se propone realizar para la consecución de su fin societario, mientras que la actividad es el ejercicio efectivo de los actos realizados por la sociedad en funcionamiento.

Basado en la diferencia entre uno y otro concepto, el art. 19 de la ley 19.550 distingue entre sociedad de objeto lícito con actividad ilícita cuál sería el caso de la sociedad que cuenta con un objeto social que comprenda la importación y exportación, pero que ha realizado actos susceptibles de encuadrar en el delito de contrabando. Del mismo modo, una actividad de los administradores que implique infracción a las leyes tributarias, impositivas o previsionales y que revistan cierto grado de permanencia, hacen incurrir a la sociedad en la causal nulificante prevista por el art. 19 de la ley 19.550.

§ 37. EL PLAZO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD

Entre los requisitos que la ley impone a la voluntad de las partes que celebran un contrato de sociedad (art. 11, inc. 5º, ley 19.550) se encuentra el plazo de duración que debe ser necesariamente determinado, por las siguientes razones:

a) Brinda seguridad a los socios, que así conocen la existencia de sus derechos y obligaciones.

b) Otorga seguridad a los acreedores particulares de los socios, en tanto la sociedad no puede ser prorrogada si no media conformidad de estos (art. 57, ley 19.550).

c) Permite la consecución del objeto social, atento a la permanencia que implica la determinación de los socios de mantenerse unidos durante un determinado lapso.

La ley 19.550 no fija plazos máximos ni mínimos de tiempo, solo exige determinación al plazo de duración de la sociedad. Los usos y costumbres han consolidado en nuestro medio la práctica de establecer un plazo máximo de 99 años, de muy dudosa validez, pues ese plazo supera con creces la vida útil de sus partícipes, salvo tratándose de personas jurídicas.

El vencimiento del plazo de duración provoca la disolución de la sociedad, pero ella puede ser evitada si los socios, de conformidad con las mayorías requeridas legalmente de acuerdo con el tipo social de que se trata, resuelven la prórroga de la sociedad, siempre y cuando tal acuerdo sea adoptado antes del vencimiento del plazo de duración y su trámite registral iniciado también antes de este acontecimiento.

CAPÍTULO V - LA PERSONALIDAD JURÍDICA DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES

§ 38. CONCEPTO. IMPORTANCIA

Por expresa disposición del art. 2º de la ley 19.550, *la sociedad es un sujeto de derecho, con el alcance fijado en esa ley.*

Mediante esta categórica definición, en concordancia con lo dispuesto por el art. 143 del Cód. Civ. y Com., el legislador ha otorgado a las sociedades el carácter de sujeto de derecho, como lo ha hecho con todas las personas jurídicas, las cuales tienen una personalidad distinta de la de sus miembros.

De tal modo, los miembros de la persona jurídica no responden por las obligaciones contraídas por ella, excepto en los casos previstos por el art. 54, párr. 3º, de la ley 19.550 y 144 del Cód. Civ. y Com.

La atribución del carácter de "personas" a las sociedades comerciales (arts. 141 y 143, Cód. Civ. y Com., y 2º, ley 19.550) constituye el efecto más característico del contrato de sociedad, pues al reconocerles la ley el carácter de sujeto de derecho, ha considerado a la sociedad como una persona diferente a la de sus integrantes, de manera tal que los derechos y obligaciones que aquella adquiere son imputados a la propia sociedad y no a cada uno de sus integrantes ni a todos ellos.

Del mismo modo, el reconocimiento de la personalidad jurídica, o lo que es lo mismo, el carácter de sujeto de derecho que tienen las sociedades, como sucede con todas las personas jurídicas, implica atribuirles ciertas cualidades o propiedades de que gozan todas las personas, tanto físicas como jurídicas, *que se denominan los atributos de la personalidad* y que son los siguientes:

a) El nombre de la sociedad, que es la designación exclusiva que la individualiza y que permite que los efectos de los actos celebrados por determinados sujetos que lo emplean se imputen directamente al patrimonio de la sociedad (art. 151, Cód. Civ. y Com.).

b) El patrimonio, que es el conjunto de bienes de la sociedad (art. 154, Cód. Civ. y Com.).

c) La capacidad, esto es, su aptitud para adquirir derechos y obligaciones (art. 22, Cód. Civ. y Com.).

Los atributos de la personalidad de las sociedades presentan iguales caracteres a los de las personas físicas, esto es, son únicos, necesarios e indisponibles, de manera tal que la sociedad no puede modificar su nombre, salvo razones fundadas, ni tampoco enajenarlo, como si se tratara de un nombre comercial.

§ 39. FUNDAMENTOS Y ALCANCE DEL RECONOCIMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA A LAS SOCIEDADES

El reconocimiento que la ley 19.550 ha efectuado del carácter de sujeto de derecho de las sociedades no tiene el mismo fundamento del que disfrutaban las personas de existencia física, pues la personalidad jurídica de estas proviene de la naturaleza misma del ser humano.

Por el contrario, la reconocida personalidad jurídica de los entes ideales en

general tiene otro fundamento. En el caso de las sociedades, el reconocimiento de su personalidad jurídica se funda en fines eminentemente prácticos, pues satisface múltiples necesidades del mundo de los negocios porque: a) por una parte y fundamentalmente, satisface los intereses de los terceros vinculados de una manera u otra con la sociedad, a quienes se les ofrece un patrimonio especial (el de la compañía) destinado a satisfacer las deudas contraídas por los representantes de la entidad, y b) por el otro, permite a los socios obtener en mejores condiciones las ventajas de los capitales aportados y de los esfuerzos asociados, independizándose el patrimonio formado para el desarrollo de la actividad social del patrimonio de sus integrantes, que en principio permanece indiferente al riesgo empresario.

En definitiva, el carácter de la personalidad jurídica de las sociedades es meramente instrumental y por ello, otorgado por el legislador cuando de tal reconocimiento se derivan beneficios para el interés general.

§ 41. LÍMITES AL RECONOCIMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA. EL CONOCIDO FENÓMENO DEL ABUSO DE LA PERSONALIDAD DE LAS SOCIEDADES

Toda vez que la personalidad jurídica se reconoce para facilitar el cumplimiento de ciertos fines de naturaleza práctica, resulta de toda lógica sostener que, cuando la utilización de ella se desvía de tales fines o cuando se abusa de esa personalidad para fines no queridos al otorgarla, es lícito atravesar o levantar el "velo" para aprehender la realidad que se oculta tras ella y aplicar la normativa correspondiente a quienes pretendieron eludirla mediante tan ilegítima manera de proceder.

§ 42. EL ART. 54, *IN FINE*, DE LA LEY 19.550. CONTENIDO Y ALCANCE

La ley 22.903 del año 1983 vino a reglamentar la amplia fórmula prevista por el art. 2º de la ley 19.550, la cual, si bien reconocía el carácter de sujeto de derecho de las sociedades comerciales, tal separación patrimonial resultaba vigente en tanto y en cuanto se respetaran "los alcances fijados por la ley".

El nuevo art. 54, *in fine*, de la ley 19.550, bajo el título de "Inoponibilidad de la persona jurídica", complementó aquel principio general describiendo los presupuestos de aplicación de la doctrina de la inoponibilidad y reglamentando sus efectos. Prescribe textualmente esta disposición legal: "La actuación de una sociedad que encubra la consecución de fines extrasocietarios o constituya un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe, o para frustrar derechos de terceros, se imputará directamente a los socios o a los controlantes que la hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados".

CAPÍTULO VI - FORMAS DE CONSTITUCIÓN. PUBLICIDAD Y REGISTRACIÓN DE SOCIEDADES COMERCIALES

§ 46. FORMA DEL CONTRATO DE SOCIEDAD

La ley 19.550 ha creado un sistema específico con relación a la forma del contrato de sociedad, cuyo principio general se encuentra previsto en su art. 4º, según el cual el contrato por el que se constituye o modifica una sociedad debe otorgarse por instrumento público o privado, en cuyo caso las firmas de los otorgantes deberán ser autenticadas por escribano público u otro funcionario competente o ratificadas ante la autoridad de control (art. 5º, ley 19.550).

La excepción a dicha regla, respecto de las sociedades previstas en la ley 19.550, se encuentra prevista para la constitución de sociedades por acciones en el art. 165 de la citada ley, que prescribe que dichas sociedades se constituyen por instrumento público y por acto único o por suscripción pública.

Surge pues de dichas normas que, para constituir una sociedad regular, el contrato constitutivo debe formularse por escrito, en instrumento público o privado, salvo para las sociedades por acciones, las cuales, cuando se trata de constitución por acto único, requieren el instrumento público, que será común, aunque no necesariamente la escritura pública, pues es posible constituir las por cualquiera de los actos previstos por el art. 289 del Cód. Civ. y Com.

Cabe recordar que el acto constitutivo de la sociedad anónima es el que debe otorgarse por instrumento público, pues así lo impone el art. 165 de la ley 19.550, y los trámites administrativos que requiere su inscripción no le dan ese carácter, porque si así fuera, la solución prevista por dicho artículo sería redundante.

§ 47. INSCRIPCIÓN DE LA SOCIEDAD EN EL REGISTRO PÚBLICO

Además de la forma escrita, la ley 19.550 requiere para calificar como regular a una sociedad mercantil su inscripción en el Registro Público de Comercio — hoy denominado "Registro Público" por el Código Civil y Comercial de la Nación, reiterando la vieja y derogada directiva del art. 36 del Cód. Com.—.

Dicha inscripción es requerida a los efectos de dar publicidad a los actos o documentos que se inscriben en el Registro Público y tornarlos oponibles a los terceros, de manera que estos no puedan alegar, a partir de tal registración, desconocimiento del contenido de tales actos o documentos.

La inscripción obligatoria de documentos comerciales tiene como fundamento el bienestar del comercio y la transparencia de las relaciones mercantiles. Concretamente, y en materia de sociedades, al tercero no solo le interesa conocer el contrato constitutivo de la sociedad y sus posteriores modificaciones, sino también otros actos cuya registración expresamente requiere la ley 19.550 a los fines de brindar certeza y seguridad jurídica a los terceros, como, por ejemplo, toda designación y cesación de los administradores o liquidadores, la disolución de la sociedad, la cancelación de su inscripción original, etcétera.

La inscripción de las sociedades en el Registro Público se encuentra prevista en el art. 5º de la ley 19.550, cuyo texto fue reformulado por la ley 26.994, prescribiendo: "El acto constitutivo, su modificación y reglamento, si lo hubiese, se inscribirán en el Registro Público del domicilio social y en el Registro que

corresponda al asiento de cada sucursal, incluyendo la dirección donde se instalan a los fines del art. 11, inc. 2º. La inscripción se dispondrá previa ratificación de los otorgantes, excepto cuando se extienda por instrumento público o las firmas sean autenticadas por escribano público u otro funcionario competente". Concluye el artículo mencionado disponiendo: "Las sociedades harán constar en la documentación que de ellas emane, la dirección de su sede y los datos que identifiquen su inscripción en el Registro".

§ 48. EL REGISTRO PÚBLICO. EFECTOS DE SUS INSCRIPCIONES

Uno de los cambios más profundos efectuados por el Código Civil y Comercial de la Nación ha sido la derogación del estatuto del comerciante, resultando cuanto menos curioso que este nuevo ordenamiento, dedicado al derecho civil y comercial vigente, no contiene ningún capítulo específico destinado a reglamentar la materia comercial, las obligaciones de los comerciantes, los agentes auxiliares ni la jurisdicción mercantil. Del mismo modo, no ha sido feliz el Código Civil y Comercial de la Nación con la supresión del Registro Público de Comercio, al cual denomina "Registro Público". De modo entonces que, como consecuencia de la derogación del Código de Comercio, las inscripciones societarias pasan a estar legisladas exclusivamente por la ley 19.550, así como las leyes 22.315, reglamentaria de la actuación de la Inspección General de Justicia y 22.316 de Registro Público de Comercio.

La ley 19.550 otorga a la inscripción del acto constitutivo de la sociedad en el Registro Público un efecto constitutivo, pues solo a partir de tal acto las cláusulas del contrato social o estatuto pueden ser opuestas a terceros, considerándose regularmente constituida a la sociedad solo desde ese momento (art. 7º, ley 19.550).

CAPÍTULO X - DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS

§ 87. EL ESTADO DE SOCIO

El estado de socio implica para este la asunción de una determinada actuación ante la sociedad que integra, sus órganos y frente a sus consocios, pues una vez que ha accedido a este carácter, por su intervención en el acto constitutivo de la entidad o por su incorporación voluntaria posterior, el socio se convierte en titular de una serie de derechos y obligaciones que han sido expresamente previstos por la ley 19.550 para poder lograr el desarrollo y cumplimiento del fin societario.

Sin embargo, el estado de socio no es uniforme en todos los tipos sociales, pues en las denominadas sociedades de interés o de personas (sociedades colectivas, de capital e industria y en comandita simple) e incluso en las sociedades de responsabilidad limitada en algunos casos, la relación personal entre el socio y la sociedad es mucho más intensa y directa que en otros tipos societarios, a punto tal que el grave incumplimiento de sus obligaciones puede acarrearle al socio la exclusión de la entidad (art. 91, ley 19.550), lo que no sucede en las sociedades anónimas, en las cuales, al haberse privilegiado el capital aportado por sobre la persona de su aportante, los derechos de sus

integrantes no siempre se ejercen en forma directa (derecho de denuncia, de información y de convocatoria a asamblea) y se encuentran además mucho más reglamentados, atento a la complejidad de funcionamiento que es de esperar en estos tipos societarios. Por otra parte, y también a diferencia de las sociedades de personas, el grave incumplimiento de las obligaciones que pesan sobre el accionista no le provoca la exclusión del ente, lo cual constituye un grave error del legislador, al menos en las sociedades anónimas cerradas, que, en su conformación y funcionamiento, son casi idénticas a las sociedades de personas.

CAPÍTULO XI - ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES

§ 93. CONCEPTOS GENERALES

En principio, debe distinguirse entre **administración y representación** de la sociedad. La **administración** importa la deliberación de la decisión de su órgano y pertenece a la esfera interna del ente, mientras que la **representación** se refiere a la esfera externa, es decir, a la vinculación de la sociedad con los terceros, pues quien tiene a su cargo la representación o el uso de la firma social obliga a la sociedad por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social.

Las diferencias entre administración y representación se advierten con mayor nitidez en las sociedades anónimas, donde el órgano de administración es necesariamente colegiado, salvo cuando el directorio se haya organizado en forma unipersonal. En tal caso, la adopción de la política de administración en todos sus ámbitos está en manos del directorio, pero la ejecución de las decisiones adoptadas por este órgano, cuando se trata de la celebración de actos frente a terceros, está a cargo del presidente de la sociedad y no en manos de cualquiera de los integrantes del directorio.

En los restantes tipos sociales, en los cuales no es para nada habitual la organización del órgano de administración en forma colegiada, los administradores revisten por lo general el carácter de representantes de la sociedad, confundándose en la misma o mismas personas físicas ambas calidades.

Puede entonces afirmarse que la **representación** es el medio en cuya virtud la sociedad se manifiesta frente a terceros, mientras que la **administración** es un concepto que abarca las relaciones internas de organización societaria.

CAPÍTULO XII - DE LA DOCUMENTACIÓN Y DE LA CONTABILIDAD

§ 103. FUNDAMENTO DE LA NECESIDAD DEL COMERCIANTE DE LLEVAR REGISTROS CONTABLES

La obligación de los comerciantes, individuales o colectivos de llevar registros contables surge imperativamente del art. 320 del Cód. Civ. y Com., en cuanto dispone que están obligados a llevar contabilidad todas las personas jurídicas privadas y quienes realizan una actividad económica organizada o son titulares

de una empresa o establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicios, disponiendo asimismo —y ello constituye una novedad fundamental que la diferencia de las viejas prescripciones del Código de Comercio en materia de contabilidad— que cualquier otra persona puede llevar contabilidad si solicita su inscripción y la habilitación de sus registros o la rubricación de sus libros.

La importancia de la contabilidad puede ser advertida desde numerosos puntos de vista:

a) En beneficio de la comunidad y del tráfico mercantil, por dos razones fundamentales: 1) interesa a los terceros que contratan con el comerciante, porque les permite conocer la evolución de sus negocios, así como su estado patrimonial y financiero en un momento determinado, y 2) permite la reconstrucción del patrimonio del comerciante, lo que cobra especial importancia en caso de concursos o quiebras.

b) En interés del comerciante mismo, pues además de permitirle el conocimiento del estado y evolución de sus negocios, la ley le permite valerse de ellos, cuando la contabilidad es llevada en legal forma, para probar de manera rápida y eficaz sus operaciones en caso de conflicto (art. 330, Cód. Civ. y Com.).

c) Finalmente, y tratándose de sociedades, solo una regular contabilidad permitirá a los socios ejercer con plenitud su inderogable derecho de información sobre la marcha de los negocios sociales y sobre la gestión de los administradores (art. 55, ley 19.550).

§ 104. LOS LIBROS SOCIETARIOS

Las sociedades deben llevar otros libros obligatorios y con las mismas formalidades exigidas para los libros de comercio, cuya importancia trasciende notoriamente el ámbito privado de ellas y en los cuales deben reflejarse actuaciones internas de la sociedad. Ellos son los libros de Actas de los Órganos Colegiados (asambleas y directorio), el libro de Registro de Asistencia a las Asambleas y el libro de Registro de Acciones.

§ 105. LOS BALANCES Y ESTADOS CONTABLES DE LA SOCIEDAD

Los administradores de las sociedades regularmente constituidas rinden cuentas de su gestión a través de la formulación de los estados contables, cuyo contenido ha sido minuciosamente reglamentado por la ley 19.550, y que se integran con los balances (art. 63), los estados de resultados (art. 64), los cuadros e información complementaria (art. 65), la memoria del ejercicio (art. 66) y el informe de la sindicatura (art. 294, inc. 5º). Asimismo, normas técnicas de carácter contable han impuesto la obligatoriedad de completar los estados contables con un dictamen o informe escrito, suscripto por contador público independiente, que debe estar fundado en el examen de los estados contables a partir de un trabajo de auditoría elaborado de acuerdo con las normas generalmente aceptadas para ello, en donde dicho profesional opina sobre los

estados contables efectuados por los administradores de la sociedad, o se abstiene de opinar sobre dichos instrumentos.

§ 134. LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD

El trámite liquidatorio constituye un procedimiento de imprescindible tránsito por la sociedad, mediante el cual los liquidadores deberán vender los bienes que componen el activo social, pagar las deudas, así como los gastos de liquidación, para posteriormente, y en caso de resultar saldo favorable, reembolsar el capital oportunamente aportado por los socios y distribuir entre ellos su remanente.

La ley describe con minuciosidad el procedimiento liquidatorio, que no ha sido instituido en favor de los socios, sino de los terceros acreedores de la sociedad, por lo que los socios carecen de derecho de disponer de los bienes sociales o distribuirlos a su conveniencia, hasta tanto sea totalmente satisfecho el pasivo social.

Sin embargo, los usos y prácticas del comercio nos demuestran que no son aislados los casos en que las sociedades prefieren "desaparecer" de la faz de la tierra, dejando totalmente insatisfecho el pasivo social. Tal manera de actuar hace responsables solidaria e ilimitadamente a los administradores de la sociedad, pues estos son los encargados de conservar el activo de la sociedad y sobre el destino dado a los bienes de ella, responsabilidad que debe ser extendida a los síndicos, por haber permitido tan ilegítima forma de proceder (arts. 59, 274, 296 y 297, ley 19.550).